

1522345-46.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato

da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522345-46.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522345-46.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência - 2250858/2021 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 20251252 - DEL.SEC.1ª CENTRO,
189/2021 - DEL.SEC.1ª CENTRO, A01567-1/2021 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2250858 -
DEL.SEC.1ª CENTRO, 189/21/100 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNALDO ANDRADE DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1335/21

VISTOS.

AGNALDO ANDRADE DOS SANTOS, JOHAN FRANCISCO SILVA e FELIPE AUGUSTO DE MATOS
CANDIDO, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que no dia 14 de setembro de
2021, por volta das 18:40 horas, na Rua Conselheiro João Alfredo, altura do n.º
196, Mooca, nesta cidade e comarca, transportavam e traziam consigo, para fins de

traficância, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, 30 tijolos contendo 22,8kg de maconha.

Consta também que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 18:40 horas, na Rua Jesuíno Pascoal, n.º 61, apartamento n.º 21, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, guardava, para fins de traficância, 109 tijolos contendo 83,4kg de maconha e diversos sacos contendo 2,3kg de maconha, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida às fls. 154/155.

Foram apresentadas defesas preliminares.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, três testemunhas de acusação, duas de defesa e os réus foram interrogados.

Em Debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

As Defesas, por seu turno, requereram a fls. 326/332, 333/339 e 340/352, a absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pugnaram pela pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, dando conta dos 139 tijolos de maconha, localizados e apreendidos em poder dos réus.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 173/288, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahidrocannabinol.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos dos réus e das Doutas Defesas não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra eles derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações dos próprios increpados, que nada de exculpatório trouxeram aos autos.

Na fase inquisitiva, o réu JOHAN declarou que estava no veículo conduzido por Agnaldo; que as drogas são de Agnaldo e seriam entregues na região da Mooca; não conhece Felipe e conheceu Agnaldo há dois meses; que receberia a quantia de R\$ 1.000,00 somente pela indicação do cliente, fls. 20. Em juízo, alegou que eu conheci Agnaldo quatro meses antes do ocorrido. Sou usuário de maconha, teve um dia que eu estava ao lado do ponto dele, estava fumando ao lado dele, quando ele disse que eu não precisava ficar escondendo dele. Um amigo perguntou se eu conhecia alguém que pudesse levar droga para esse meu amigo. Eu perguntei pro Agnaldo que disse que sim, e só pela indicação, ele ia me pagar para eu acompanhar a venda. Eu tinha sido demitido, então vi uma oportunidade de deixar minhas contas em dia. Tenho duas filhas pequenas. Entrei em contato com Agnaldo, dizendo que meu amigo queria dez quilos de maconha. Agnaldo disse que me pagaria uma comissão. A gente estava levando a droga para esse amigo, e eu fui junto porque o amigo era meu. O restante da droga eu não tinha conhecimento. Agnaldo me disse que depois ia fazer outra entrega, mas eu não poderia ir com ele. Estou super arrependido. Confesso que realmente estava praticando os fatos, tinha conhecimento da negociação e das drogas. Tenho 23 anos de idade, nunca tive passagem nenhuma. Não conhecia o réu Felipe, conheci ele na delegacia.

É certo que a confissão sozinha não se presta a sustentar todo o édito de uma condenação. Mas é certo também que, quando vem acompanhada dos demais elementos probatórios carreados aos autos, como na presente circunstância, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção. Mesmo porque, não se pode crer que o réu estivesse em um veículo transportando tamanha quantidade de maconha, não fosse para o exercício da traficância.

O réu AGNALDO confessou que as drogas foram encontradas em seu veículo, bem como em sua residência por ele mesmo indicado aos policiais; que Johan estava acompanhando para fazerem uma entrega de um cliente; que Felipe é seu sobrinho de consideração e que estava em sua casa apenas lhe visitando, não tendo qualquer relação com as

drogas, fls. 21.

Em juízo declarou que eu trabalho como taxista há 25 anos, só que de alguns anos para cá caiu muito. No dia dos fatos eu peguei Johan para fazer uma entrega de dez quilos de maconha para um amigo dele. Eu levei os policiais para o meu apartamento, para facilitar. Eu sabia que Felipe estaria lá. A mãe dele me ligou para eu levar Felipe até o hotel. A mãe dele pediu para eu buscar Felipe no Centro e levar no hotel. Eu sabia que Felipe estaria na minha casa, onde ele chegou por volta das seis da tarde, mas quando levei a polícia lá, achei que ele não estaria mais lá. Essas drogas que estavam na minha casa, tinha dois dias que eu tinha pego para entregar para os clientes. Minha mulher não sabia. Mas no dia estava sim um cheiro forte de drogas. Nunca fui preso antes.

Da mesma forma que ocorre com o réu JOHAN, aqui a confissão do acusado é corroborada pelos demais elementos probatórios destes autos. O montante de drogas apreendidas em poder do réu não deixa dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio.

Já o réu FELIPE declarou na fase inquisitiva que estava no apartamento do seu tio de consideração, Agnaldo, após ter vindo de sua residência em Pitangueiras/Guarujá; que os policiais chegaram e encontraram maconha; não sabia que havia maconha no apartamento e que estava no local somente aguardando o horário do rodízio, pois sua placa é BYI-0733, fls. 19.

Em juízo, declarou que no dia dos fatos eu recebi uma mensagem da minha mãe, para eu ir para São Paulo, para a gente se reunir, porque ela tinha chegado dos Estados Unidos, jantar. Chegando em São Paulo, deixei minha filha e minha mulher no salão e fui lavar o carro. Parei na frente do lava-rápido, que é perto do Mackenzie, e fui para uma hamburgueria esperar o carro. Nisso encontrei alguns amigos, e acabei esquecendo da hora. Quando vi que horas eram, corri para o lava-rápido, e peguei meu carro. Foi quando o dono me lembrou que era rodízio do meu carro. Então eu liguei para minha mãe e pedi para ela mandar alguém vir me buscar e minha esposa. Nisso ela falou para eu ir para casa do Agnaldo esperar ele lá que ele ia me buscar lá. Eu fui andando para casa do Agnaldo, a esposa dele me recebeu e fiquei assistindo TV. Ela saiu para ir ao mercado, nisso, passados uns minutos, escutei um barulho na porta, e quando fui ver, eram os policiais. Eles perguntaram se eu tinha passagem, eu disse que sim, mas atualmente não fazia mais isso. Não conhecia o réu Johan. Quando eu cheguei no apartamento, eu pensei que Agnaldo fumasse maconha por causa do cheiro. Eu conheço ele há muitos anos, ele conhece minha família, minha mãe conhece ele há muito tempo. Já fui condenado por tráfico e roubo. Eu já tinha ido na casa do Agnaldo no aniversário dele e da esposa dele.

Pois bem, enquanto as confissões dos réus Agnaldo e Johan vieram embasadas pelas demais provas produzidas nos autos, as tentativas deles em isentar o réu Felipe, bem como as negativas deste, vieram isoladas e em absoluto não convencem.

A confusa versão apresentada por FELIPE mostra-se no mínimo pueril. Como se vê, diz ele inicialmente que pediu para sua mãe mandar alguém vir lhe buscar por conta do rodízio de seu carro. Daí, acabou indo para casa do réu AGNALDO justamente no exato momento em que ele fazia uma entrega de grande quantidade de maconha, sem ter conhecimento da prática ilícita que se sucedia. Veja que ele poderia aguardar o horário do rodízio em qualquer outro lugar, sendo que não estava utilizando os serviços de taxista de AGNALDO no momento em que foram detidos. Assim sendo, não se pode crer que FELIPE estaria à espera no apartamento em questão caso não estivesse ali justamente para guardar os entorpecentes ali armazenados.

Até mesmo porque há contradições significativas entre os relatos dos réus no que tange à motivação da presença de FELIPE no apartamento de AGNALDO no momento dos fatos. AGNALDO não soube explicar se sabia que o outro estava em sua casa e nem o porquê de sua presença ali. Veja que ele afirma que a mãe de FELIPE havia requisitado seu serviço de motorista para levá-lo a um hotel por conta do rodízio, mas em seu relato AGNALDO diz que confessou aos policiais que havia drogas em seu apartamento sem mencionar FELIPE porque acreditava que o outro já havia saído de sua residência.

Desta forma a autoria por parte de todos os acusados é patente nos autos. Não se

pode crer que os acusados JOHAN e AGNALDO estivessem por acaso juntos, em poder de grande quantidade de drogas, acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

E, da mesma forma, não há como crer que FELIPE estaria no apartamento onde estava armazenada grande quantidade de maconha no exato momento em que AGNALDO participava de uma entrega junto com o outro réu, sem justificativa clara para tanto.

Dessa forma, não se tem nos autos, a despeito dos argumentos da Douta Defesa, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar os réus ou mesmo acusá-los falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a existência de denúncia anônima, a grande quantidade de drogas encontradas tanto no carro utilizado para os serviços de taxi como na residência, os objetos característicos ao tráfico apreendidos, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto que os policiais civis responsáveis pela prisão dos réus, Fernando Henrique Gomes Teixeira, Alex Teixeira da Silva e João Carlos, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme e segura que nós tínhamos a informação de que um veículo Nissan branco estaria transportando drogas, e também informações sobre o local, na região da Mooca. Fomos em buscas pela região, quando nos deparamos com um veículo Nissan branco, que era taxi, porém levava um passageiro no banco da frente. Optamos pela abordagem, quando sentimos forte odor de maconha. No porta malas do carro, foram encontrados os tijolos de maconha. Nós estávamos em duas viaturas, uma caracterizada e outra descaracterizada. No trajeto para delegacia, um deles, que estava na viatura descaracterizada, o réu Agnaldo nos passou o endereço dessa residência, onde encontramos o réu Felipe, que nos franqueou a entrada. No interior dessa residência havia também grande quantidade de drogas. Felipe disse que havia acabado de chegar da praia e que a casa era do Agnaldo, e que estava lá aguardando ele. O comportamento dele foi calmo, abriu a porta e disse que não sabia das drogas, que apenas estava lá esperando seu amigo Agnaldo. O réu Agnaldo era quem conduzia o carro. Reconheceram os réus e não os conheciam anteriormente.

Os policiais civis narraram com segurança e precisão como se deu a prisão dos acusados, relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local em razão de diligências investigativas em relação ao veículo apontado como transporte de drogas, ordem de parada, a abordagem de AGNALDO dirigindo o táxi e JOHAN como passageiro, o encontro das drogas no porta-malas, o momento em que AGNALDO confessou possuir mais drogas em sua residência, a chegada na residência sendo recebidos por FELIPE, o encontro das drogas e apetrechos como guilhotina e balanças dentro de um cômodo, inclusive abriram o cômodo com a chave fornecida por AGNALDO, até final detenção e prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na

parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Ademais, foram ouvidas duas testemunhas de defesa.

A primeira delas, Mirian da Silva Costa, ouvida em Juízo relatou que conhece o réu Felipe que é primo do meu marido. Felipe trabalha comigo em um box, ele faz as compras para mim, e quando eu preciso sair ele cuida do box para mim. Ele trabalha comigo todos os dias. Nós trabalhamos aqui em São Paulo, mas ele mora no Guarujá e vem todos os dias para São Paulo. Ele se hospeda na casa da mãe dele. O réu Agnaldo é apenas taxista da nossa família. Ele não é parente nosso. O réu Felipe não costuma dormir na casa do Agnaldo porque a mulher dele é ciumenta e fica muito no pé dele. A mãe do réu Felipe mora no Guarujá. No dia dos fatos era rodizio do carro do Felipe, e a mãe dele estava hospedada no Hotel Renascense, porque tinha acabado de chegar dos Estados Unidos.

A outra testemunha Elizabeth de Matos Candido, mãe do réu Felipe, ouvida como informante declarou que eu moro nos Estados Unidos. No dia que cheguei foi no dia dos acontecimentos. Eu liguei para o meu filho e disse para ele ir para o Guarujá, e depois por volta das sete da noite você para o hotel, porque meu marido é Capitão da Delta, e eu queria que jantássemos todos juntos. Era rodizio do carro do réu Felipe, então eu disse para ele ligar pro Agnaldo, que era o taxista da família para traze-lo, que depois eu ia com Agnaldo para praia. Nós ficamos esperando meu filho, nem Agnaldo atendia o telefone. Nisso os policiais me ligaram, dizendo que meu filho havia sido preso. Eu fui para delegacia, os investigadores me levaram para onde meu filho estava. Atrás do meu filho, estava o Sr. Agnaldo, que ao me ver, colocou as mãos na cabeça e pediu desculpas para mim, porque quem apresentou o Sr. Agnaldo para meu filho fui eu. Porque ele tinha um ponto de táxi em frente de onde eu morava, então ele virou motorista da família e ganhou nossa total confiança. Tenho conhecimento de que meu filho foi condenado por roubo e tráfico. E quando ele saiu da cadeia eu e meu marido demos todo suporte para ele. Demos um cartão de crédito para ele com mais de 30 mil reais de saldo. Fizemos tudo para ocupar a cabeça do meu filho, cursos de inglês, DJ. Meu filho mora no Guarujá, no apartamento que eu e meu marido demos para ele, mas ele vem trabalhar todos os dias em São Paulo. O réu estava na casa do Agnaldo porque, eu soube depois, Agnaldo pediu para Felipe ir para casa dele e esperar com ele lá.

Ocorre, porém, que os depoimentos das testemunhas de defesa, ao contrário do que ocorre com os depoimentos dos policiais, não podem ser considerados imparciais. A uma porque não presenciaram a localização das drogas. E depois porque tratando-se de amiga e mãe do réu FELIPE, outra não poderia ser a conduta delas senão tentar, de todas as formas, inocentá-lo de tão grave acusação.

Ainda, muitas vezes, mesmo tratando-se de pessoas próximas e ligadas aos agentes, não têm conhecimento acerca da traficância que praticam.

Em que pesem, pois, os argumentos das defesas, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar os réus e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder dos réus, localizados em um veículo objeto de denúncia com envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinham substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar os acusados da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como

de conteúdo múltiplo ou variado, preencheram todos os réus um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter os agentes sido surpreendidos no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Destarte, não se evidenciou qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar os réus da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Os réus JOHAN e AGNALDO são primários e não ostentam antecedentes criminais. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Já o réu FELIPE é portador de maus antecedentes, condenado por outro tráfico, conforme certidão de fls. 62, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. Assim nesta primeira fase, elevo sua pena base em 1/6, perfazendo, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase o réu FELIPE é reincidente, conforme certidão de fls. 61 e 73, assim, aumento sua pena em mais 1/6, perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em relação aos réus JOHAN e AGNALDO, na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque os acusados primários, sem quaisquer antecedentes, confessaram as autorias delitivas, e não há um indício sequer a demonstrar que façam parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a quantidade de drogas, reduzo a pena base em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em relação ao réu FELIPE, não há que se falar em aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o condenado é reincidente específico e foi detido com grande quantidade de drogas, circunstâncias estas suficientes a afastarem os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e aplicação da redução em apreço, nada havendo, portanto, que demonstre que não faz do crime um meio de vida.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar JOHAN FRANCISCO SILVA e AGNALDO ANDRADE DOS SANTOS, a cumprirem, em regime inicial semiaberto, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, como incursos nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº11.343/06, e FELIPE AUGUSTO DE MATOS CANDIDO, como incurso nas penas do artigo 33, da Lei nº11.343/06 a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão mais pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Os condenados AGNALDO e JOHAN iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, pois são primários confessaram os fatos, e encontram-se presos há mais de quatro meses, de sorte que o regime mais brando se justifica.

Saliento que nem mesmo a atual decisão do STJ é capaz de ser aplicada ao presente caso, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu. Tanto é assim que, analisando temas semelhantes, o STF já firmou entendimento no sentido de ser plenamente possível o reconhecimento da minorante prevista na Lei de Drogas, em conjunto com o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, sem que haja qualquer vinculação ou obrigatoriedade de ser reconhecido o regime aberto. Há que se consignar que cada caso concreto possui fatos diferentes, que afastam a obrigatoriedade e a rigidez imposta pelo STJ, de maneira que a aplicação e o reconhecimento da minorante, bem como o regime inicial da pena devem ser analisados de acordo com cada situação específica imposta e apresentada em cada processo.

No sentido vale trazer a colação o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA QUE APONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. Razão não assiste ao agravante. Consoante consignado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 413.085/SC, não reflete flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, já que alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vide: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA QUE APONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada esta última pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (crack). Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica, sem dúvida, revolver o acervo fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena

comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. – No caso, inexistente coação ilegal a ser sanada, pois, embora o paciente seja primário e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão comporte, em princípio, o regime inicial aberto, o regime intermediário foi fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada nocividade da droga apreendida (crack), elemento que, inclusive, justificou a escolha da fração redutora de 1/3 pelo tráfico privilegiado. Inteligência dos art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n.

11.343/2006. Precedentes. – No que tange à possibilidade de substituição da pena – Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art.

33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. – Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada esta última pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (crack). Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica, sem dúvida, revolver o acervo fático-

probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n.

8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. – Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em

elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. – No caso, inexistente coação ilegal a ser sanada, pois, embora o

paciente seja primário e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão comporte, em princípio, o regime inicial aberto, o regime intermediário foi fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada nocividade da droga apreendida (crack), elemento que, inclusive, justificou a escolha da fração

redutora de 1/3 pelo tráfico privilegiado. Inteligência dos art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44 do Código Penal, reconhecendo a

inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012. – Na espécie, embora adimplido o requisito objetivo previsto

no art. 44, I, do CP, a nocividade do entorpecente apreendido (crack) não recomenda a substituição, nos termos do inciso III do art. 44 do CP. Precedentes. – Habeas corpus não conhecido” (fls. 428/429 e-STJ).

De outra banda, não é possível, contudo a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em

apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram. No mesmo sentido, foi a recente decisão

proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: “Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a

aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06

expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes,

goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de

República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, "caput", da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Já o condenado FELIPE iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, pois é reincidente, possui péssimos antecedentes e o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8072/90 prevê expressamente, que crimes dessa natureza, terão suas penas cumpridas inicialmente em regime fechado.

Além do mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, elencado pela Constituição Federal como inafiançável, sendo vedada a liberdade provisória, antes da condenação definitiva, quando prevalece a presunção de inocência, muita mais descabida é a concessão de qualquer regime diverso, com possibilidade de liberdade cautelar àquele que vem a ser condenado, mesmo que em primeiro grau.

Em arremate, os condenados responderam a todo o processo presos e assim devem permanecer, pois foi nesta data condenados a crime de extrema gravidade, dos quais não se admite liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06. A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em especial, da prática de crimes como deste jaez, cujos agentes não se privam em aliciar jovens em nossas comunidades, causando transtornos irreparáveis em todos os cidadãos de bem.

Assim sendo, presentes os requisitos legais, não concedo aos condenados o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função

de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se o réu FELIPE no estabelecimento prisional que se encontra recolhido, bem como a remoção dos réus AGNALDO e JOHAN para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA